

Avv. Paolo Caruso
Via Eustachio Manfredi n. 5
00197 – Roma
Tel. 06.8084487 - Fax 06.87813040
paolocarus@ordineavvocatiroma.org
paolo.caruso@legalecaruso.it

ILL.MA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

per **FASTWEB S.p.A.** (C.F. e P.IVA 12878470157), Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 – Milano (MI), in persona della Dott.ssa Simona Serchi, nella sua qualità di procuratore, per procura del 4.12.2023, Rep. n. 42295, Racc. n. 16755, notaio E. Terrenghi, rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Paolo Caruso (C.F. CRSPLA79R09H501Y; PEC paolocarus@ordineavvocatiroma.org; telefax 06.87813040), con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore;

CONTRO

il **COMUNE DI BERBENNO** (C.F. e P.IVA 00313890162), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Europa n. 7 – 24030 Berbenno (BG), PEC: comuneberbenno@legalmail.it, elettivamente domiciliato presso il difensore di primo grado, Avv. Maria Voccia De Felice, PEC mvocciaordsa@pec.giuffre.it;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

della Sentenza n. 1523/2025 resa dal Tribunale di Bergamo (**doc. A**), Sez. II Civile, dott. Paolo Rossi in data 25.11.2025, notificata il 28.11.2025 (**doc. A-bis**), che ha respinto le domande di Fastweb S.p.A. proposte nel giudizio R.G. n. 2320/2025 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 06.02.2025 (**doc. 1**) notificato dal Comune di Berbenno (BG) il 15.02.2025, per il preteso pagamento del “*canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” di cui all'art. 1, co. 816 della Legge n. 160/2019, per le annualità dal 2021, 2002, 2023 e 2024, in pretesa applicazione dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 (cavi e condutture), per il ritenuto “*utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione, attraverso collegamenti tecnologici, senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà*”.

* * * * *

PREMESSA

1. L'avviso di accertamento esecutivo.

Con **avviso di accertamento esecutivo** n. 1 del 6.2.2025 (**doc. 1**), notificato via p.e.c. il 15.2.2025 (**doc. 2**), il Comune di Berbenno, richiamata la normativa sul canone unico patrimoniale e il relativo Regolamento comunale (**doc. 3**) e ritenuto che *“Fastweb S.p.A. utilizza in via mediata la rete telefonica del soggetto titolare della concessione”* ha intimato a Fastweb S.p.A. di pagare entro 60 giorni la somma di € **7.173,00**, delle quali: € 800,00 a titolo di *“canone unico patrimoniale”* per l'anno 2021; € 830,40 a titolo di *“canone unico patrimoniale”* per l'anno 2022; € 924,24 a titolo di *“canone unico patrimoniale”* per l'anno 2023; € 929,79 a titolo di *“canone unico patrimoniale”* per l'anno 2024; € 3.484,43 a titolo di *“sanzione amministrativa pecuniaria”*, fissata in misura pari al canone non versato per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024; € 204,43 per *“interessi”* dalla scadenza di ciascuna annualità di canone. Nella sezione *“motivazione dell'atto”* viene precisato che il canone sarebbe dovuto *“per l'utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione”* e, dunque, a prescindere dall'esistenza di un'occupazione fisica del territorio comunale e indipendentemente dall'utilizzo materiale dell'infrastruttura. Inoltre, ai sensi dei commi 792 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che disciplinano l'avviso di accertamento esecutivo, l'atto avverte della propria idoneità ad acquistare *“... efficacia di titolo esecutivo”*.

*

2. Il giudizio di primo grado (Trib. Bergamo; RG 2320/2025).

Con atto di citazione notificato il 16.4.2025, Fastweb S.p.A. ha impugnato il predetto avviso di accertamento esecutivo, formulando le seguenti conclusioni:

“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, accertato che Fastweb S.p.A. non è concessionaria dell'infrastruttura di rete sita su territorio comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, in tutto in parte, l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 6.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno, e ogni altro atto o

avviso ad esso connesso o consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto da Fastweb S.p.A. al Comune di Berbenno per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 a titolo di canone unico patrimoniale, indennità, interessi e, comunque, a titolo di sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”

Fastweb segnalava, in punto di fatto, di non essere titolare di alcuna concessione nel territorio comunale relativa a ‘cavi e condutture’ e di non esercitare alcuna occupazione, tantomeno abusiva, del suolo pubblico, ma di rivestire esclusivamente il ruolo di Società di vendita, avvalendosi del servizio fornito dal concessionario e titolare della rete (Open Fiber) in base ad accordi contrattuali onerosi e regolamentati da AGCom e secondo le modalità tecniche illustrate alle pagg. 5-8 dell’atto di citazione, rimaste incontestate.

Pertanto, Fastweb lamentava il difetto di soggettività passiva, spettando quest’ultima esclusivamente al titolare della concessione (Open Fiber, oltre che a Telecom Italia, storico concessionario della rete), formulando le censure di seguito sintetizzate:

- I) Violazione dell’art. 5, co. 14-quinquies del D.L. n. 146/2021 secondo il quale, nei casi di separazione tra titolarità dell’infrastruttura e del contratto di vendita, derivanti da assetti legislativi, regolamentari o contrattuali, il canone è versato “... *esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita*”;
- II) Falsa applicazione dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 che, ai fini della soggezione a canone, espressamente richiede il requisito dell’ “*utilizzo materiale delle infrastrutture*”, nella specie mancante;
- III) Nullità dell’avviso di accertamento per mancata previa formale contestazione di abusività a norma della Legge e dell’art. 36 del Regolamento Comunale;
- IV) In via subordinata, erronea quantificazione della sanzione in violazione dell’art. 58 del Regolamento Comunale

Nel giudizio così instaurato (R.G. n. 2320/2025), si costituiva il Comune di Berbenno

insistendo per la debenza del canone a titolo di “occupazione mediata” e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con la prima memoria integrativa dell’8.9.2025 (doc. B2), Fastweb, alla luce delle avversarie difese, integrava la domanda di nullità deducendo l’improprio ricorso allo strumento dell’avviso di accertamento esecutivo, non potendo dirsi la pretesa “certa liquida ed esigibile” in quanto non basata su alcun titolo (atto di concessione o verbale di accertamento di abusività o altro accertamento) né su “*idonea documentazione*” (ex art. 179 TUEL) ma affidata a meri elementi presuntivi.

All’esito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del 30.9.2025 il Tribunale fissava ex art. 281-sexies c.p.c. l’udienza di discussione del 25.11.2025.

*

3. La sentenza impugnata: sintesi della ratio decidendi e dei motivi di appello.

Con Sentenza n. 1523/2025, pubblicata il 25.11.2025 (**doc. A**), il Tribunale di Bergamo, discostandosi dall’orientamento dominante (v. ampia rassegna giurisprudenziale *sub doc. C*), ha respinto l’opposizione.

In estrema sintesi, il Tribunale:

- non ha affrontato il motivo di opposizione afferente alla violazione dell’art. 5, co. 14-*quinquies*, del D.L. n. 146/2021 (norma di interpretazione autentica): di qui il I motivo di appello che deduce omessa pronuncia e ripropone il vizio di violazione dell’art. 5, co. 14-*quinquies*, del D.L. n. 146/2021;
- ha ritenuto che anche la fruizione virtuale del servizio fornito dal concessionario e titolare della rete integra il requisito dell’ “*utilizzo materiale delle infrastrutture*” prescritto dal comma 831: di qui il II motivo di appello che denuncia la falsa applicazione dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- ha esaminato solo parzialmente la domanda di nullità, come integrata con la prima memoria, ritenendola infondata, perché asseritamente non prevista

dall'art. 36 del Regolamento comunale: di qui il III motivo di appello che deduce omessa pronuncia e ripropone la questione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto dei requisiti di certezza della pretesa;

- ha respinto la domanda subordinata, ritenendo la quantificazione della sanzione (pari al 100% del canone) rispettosa dell'art. 58, comma 3, del Regolamento Comunale che tuttavia riguarda le occupazioni abusive, mentre il comma 1 attiene agli omessi versamenti: di qui il IV motivo di appello che denuncia violazione e falsa applicazione del predetto art. 58.

*

Di tale sentenza, in quanto erronea, ingiusta e gravemente lesiva, Fastweb S.p.A. chiede l'annullamento e/o la riforma per i seguenti

MOTIVI

(PREMESSA COMUNE AI MOTIVI DI APPELLO)

Riferimenti normativi: l'art. 1, co. 831, e la norma di interpretazione autentica.

L'art. 1 della **Legge n. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020), ai commi 816 e ss., ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **c.d. canone unico patrimoniale**, che, a decorrere dal 2021, ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e altri prelievi simili.

Ai sensi del **comma 819**:

“il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; ...”.

Il successivo **comma 831**, nel testo che rileva *ratione temporis*, ha poi stabilito:

“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal

soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.

Il richiamato **comma 831** ha formato oggetto di **interpretazione autentica**, ad opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui art. 5, comma 14-*quinquies*, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone:

“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

*a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una **separazione**, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, **tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale**, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.*

In sintesi, a fronte di una non perspicua compresenza – nel comma 831 – del concetto di occupazione “*in via mediata*” e del pur necessario requisito dell’ “*utilizzo materiale delle infrastrutture*”, la norma di interpretazione autentica ha precisato che, quando il soggetto che fornisce il servizio all’utenza si avvale di infrastrutture altrui, ossia opera in forza di contratti intercorsi con il titolare dell’infrastruttura, è quest’ultimo che, quale concessionario di suolo pubblico, è l’unico soggetto passivo del canone patrimoniale. È questo il caso di specie, come ora si vedrà.

* * *

(PRIMO MOTIVO DI APPELLO)

**OMESSA PRONUNCIA; VIOLAZIONE DELL'ART 5, CO. 14-QUINQUIES
DEL D.L. 146/2021 (NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA):
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLA SOGGETTIVITÀ PASSIVA.**

I.1 La violazione di legge dedotta in primo grado.

Col primo motivo di opposizione (v. in part. pagg. 10-13 dell'atto di citazione, **doc. B1**; e pagg. 4-6 delle note conclusive: **doc. B4**) Fastweb ha denunciato l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per **violazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021** (di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019), che stabilisce la soggettività passiva del solo concessionario della rete, anche per le utenze delle c.d. Società di vendita, quale è nel caso di specie Fastweb S.p.A.

I.2 Omessa pronuncia.

L'errore più evidente della sentenza impugnata consiste nell'aver **completamente omesso di considerare la norma di interpretazione autentica** di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021

Tale norma, pur essendo stata ampiamente evocata da Fastweb in primo grado, non viene nemmeno menzionata nella sentenza impugnata.

Di qui l'evidente **omessa pronuncia**, che è anche **decisiva**.

Infatti, qualora avesse esaminato la contestazione, che viene in questa sede riproposta, il Tribunale non avrebbe potuto che annullare l'avviso di accertamento che, in violazione della predetta norma, ha preteso di assoggettare a canone di concessione anche la mera Società di vendita.

La disposizione ignorata, dotata di efficacia retroattiva, ha infatti chiarito in via definitiva che nel modello di *business* basato sulla separazione tra proprietario della rete (es. Open Fiber) e fornitore del servizio finale (es. Fastweb) – modello tipico del settore delle telecomunicazioni – la Società di vendita non è soggetto passivo del

canone, essendosi stabilito ex lege che in tali ipotesi non si configurano né un'occupazione mediata né un utilizzo materiale e, di conseguenza, il canone è dovuto esclusivamente dal concessionario, che lo calcola sul numero totale delle utenze, comprese quelle delle società di vendita, evitandosi così ogni duplicazione impositiva, nel contempo senza pregiudizio per l'Ente pubblico.

I.3 Applicabilità della norma al settore delle telecomunicazioni.

I.3.1 L'art. 5, comma 14-*quinquies*, del D.L. n. 146/2021 stabilisce che la separazione tra titolarità della concessione e titolarità del contratto di vendita **può dipendere da “assetti normativi, regolamentari o contrattuali”**.

La norma, pertanto, non contiene i limiti invocati da controparte (che ha preteso di restringerne l'applicazione ai soli settori del gas e dell'energia elettrica) e si applica in tutti i casi di fornitura in cui il titolare dell'infrastruttura non coincide col titolare del contratto di vendita.

Nel caso di specie, si determina proprio questa evenienza, avente fonte contrattuale perché derivante da accordi contrattuali onerosi intercorsi tra Open Fiber e Fastweb, per di più sottratti a libero mercato e soggetti a vaglio di AgCoM (fonte regolamentare).

La fattispecie della norma di interpretazione autentica trova inoltre corrispondenza nel dato di fatto, che è pacifico in giudizio, con la conseguenza che:

“quando il titolare dell'infrastruttura e il titolare dei contratti di vendita sono distinti, e quando il secondo si serve dell'impianto del primo senza un'attività di modificazione materiale dell'infrastruttura, è normativamente esclusa, in capo al secondo soggetto, l'occupazione “in via mediata” del suolo pubblico, costituente il presupposto dell'obbligo di pagamento del CUP. E ciò vale, per espressa previsione di legge, non solo quando detta separazione sia imposta dalla legge stessa o da regolamenti, ma anche quando essa derivi da ‘assetti contrattuali’” (Trib. Treviso, sent. 10 novembre 2025, n. 1522; cfr. doc. C, pag. 162).

Del resto, **se il Legislatore avesse voluto limitare l'intervento interpretativo ai settori dell'energia elettrica e del gas**, come sostenuto da controparte, **lo avrebbe detto esplicitamente; inoltre, non avrebbe mai richiamato ipotesi di separazione**

derivanti da assetti regolamentari o contrattuali che chiaramente alludono a settori diversi da quelli del gas e dell'energia elettrica.

Pertanto:

“nel settore delle telecomunicazioni separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale” (Cda Venezia, sent. 10 giugno 2025 n. 2093; doc. C pag. 90).

I.3.2 La **riprova** dell'applicabilità dell'art. 5, comma 14-*quinquies*, al settore delle telecomunicazioni **si rinviene nei lavori parlamentari**, posto che il Dossier D.L. 146/2021 – A.C. 3395 – richiamato invano in primo grado –, nel presentare la norma, chiarisce che:

*“il comma 14-quinquies dell'articolo 5, inserito al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di **servizi di pubblica utilità**, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi ... **si tratta di servizi quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete**” (doc. 6, pagg. 59-61; pagg. 61-63 del pdf).*

È dunque dimostrata l'intenzione del Legislatore di riferirsi a tutti i servizi di rete.

I.3.3 Inoltre, in sede di conversione in legge del successivo D.L. 228/2021 (recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), sono stati presentati due **emendamenti**, che poi non sono stati approvati, che miravano a escludere provvisoriamente il settore delle telecomunicazioni dall'applicazione dell'art. 5, comma 14-*quinquies*, sul presupposto logico scontato della onnicomprensività della norma stessa (**doc. 7**).

- Il primo emendamento non approvato è del seguente tenore:

“Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di

*concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, **l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022.** Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*

- Il secondo e alternativo emendamento, non approvato, è del seguente tenore:

*“**In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas**”. Limitazione dell'interpretazione autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al 31/12/2022*

Questi emendamenti, ripetesi non approvati, sono l'evidente e ulteriore riprova che l'art. 5, comma 14-quinquies, **si riferisce certamente anche al settore delle telecomunicazioni**. La proposta di ritardare l'applicazione della norma al settore delle telecomunicazioni non è stata tuttavia approvata perché tali emendamenti non sono stati recepiti nella Legge di conversione del D.L. n. 228/2021, con la conseguenza che la norma di interpretazione autentica certamente si applica e deve essere esclusa la soggettività passiva delle Società di vendita.

I.3.4 Né si può obiettare che la norma di interpretazione autentica svuoterebbe di ogni significato la soggettività passiva in via mediata di cui al comma 831. Quest'ultima, infatti, anche a seguito della norma di interpretazione autentica, conserva il ruolo di criterio impositivo in tutti quei casi in cui il soggetto c.d. utilizzatore, pur non avendo conseguito una concessione di suolo pubblico (che è espressione di occupazione “diretta”), abbia comunque posato proprie opere o manufatti su suolo pubblico. In quest'ultimo caso, si realizza sia l'occupazione mediata (perché l'occupazione è consentita non direttamente dal Comune ma dal concessionario di suolo pubblico) sia la materialità dell'occupazione (intervento

materiale sul suolo). Pertanto, la norma di interpretazione autentica non ha svuotato di significato la norma interpretata.

I.3.5 L'applicazione della norma di interpretazione autentica alla fattispecie di causa è inoltre sorretta dalle seguenti esigenze:

- quella di chiarire l'applicazione dei concetti apparentemente contraddittori di “*occupazione del suolo pubblico ...in via mediata*” e di “*utilizzo materiale delle infrastrutture*” ai quali si riferisce il comma 831 (norma interpretata);
- quella di tutelare l'Ente locale (e le Società di riscossione) che, in forza della norma di interpretazione autentica, potrà più agevolmente rivolgersi a un unico e certo interlocutore (il titolare della concessione, che conosce e gestisce tutte le utenze), anziché a una pluralità di società di vendita, anche molto piccole, in base al numero di utenze di ciascuna;
- quella di tenere conto che le condizioni economiche dei contratti c.d. *wholesale* intercorsi tra il titolare della concessione (grossista) e le singole società di vendita – condizioni che formano oggetto del vaglio istruttorio e dell'approvazione dell'AGCom – pongono a carico delle Società di vendita corrispettivi che sono già onnicomprensivi, che tengono conto degli oneri di realizzazione e manutenzione della rete e degli oneri di occupazione di suolo pubblico; parimenti, il titolare della concessione già si giova, nei propri rapporti con le Società, di canoni contrattuali più elevati che tengono conto degli oneri di occupazione a carico del concessionario;
- non ultima, quella di garantire la concorrenza nel settore della telefonia fissa, considerato che, a voler accedere alla tesi del Tribunale, soprattutto nei piccoli Comuni le piccole Società di vendita sarebbero disincentivate a entrare nel mercato per la necessità di corrispondere, in ogni caso, un canone minimo di € 800,00 rivalutato, anche per una sola utenza (sic !).

Pertanto, richiedere il canone anche ai “*soggetti titolari del contratto di vendita*”

quale è Fastweb nel caso che ci occupa, significa applicare erroneamente la norma e duplicare l'imposizione per una medesima fattispecie di occupazione, in **contrasto col diritto UE** (art. 13 Dir. 2002/20/CE e art. 42 Dir. UE 2018/1972), perché i contributi devono essere giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e mai “duplicati”.

I.3.6. Si deve anche aggiungere che Open Fiber S.p.A., a differenza di TIM (che fino alla cessione a Fibercop di luglio 2024 cumulava, sia pure in regime di separazione contabile e funzionale, il ruolo di concessionario con quello di Società di vendita), offre solo il servizio *wholesale* (c.d. Wholesale Only) ossia fornisce esclusivamente servizi all'ingrosso, realizzandosi con ciò, e a maggior ragione, una **netta separazione** tra gestione dell'infrastruttura e offerta di servizi all'utenza, ossia proprio la fattispecie contemplata dalla norma di interpretazione autentica.

I.3.7 Infine, il Comune ha prodotto in atti la dichiarazione TIM del 12.4.2024 (utenze alla data del 31.12.2023; doc. 6 Comune) che cita espressamente l'art. 5, comma 14-*quinquies* del D.L. n. 146/2021, a significare, da un lato, che anche secondo TIM (altro concessionario di rete storico) la norma di interpretazione autentica si applica anche al settore delle telecomunicazioni; dall'altro lato, che si deve presumere che, in ossequio alla richiamata norma di interpretazione autentica, TIM abbia dichiarato oltre alle proprie utenze, anche quelle delle c.d. Società di vendita e lo stesso, in mancanza di diversa prova (che il Comune avrebbe dovuto fornire) dovrebbe aver fatto Open Fiber S.p.A. (in relazione alla quale il Comune non ha documentato alcunché!)

In definitiva, la sicura applicabilità alla fattispecie della norma di interpretazione autentica, che il Tribunale ha del tutto ignorato, implica la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della censura di violazione di legge e l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto in primo grado, per evidente carenza della soggettività passiva di Fastweb S.p.A.

* * * * *

(SECONDO MOTIVO DI APPELLO)

FALSA APPLICAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE 160/2019. DIFETTO DEL REQUISITO DELL' "UTILIZZO MATERIALE DELLE INFRASTRUTTURE". VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. OMESSA PRONUNCIA.

II.1 Il capo della sentenza impugnato.

A fronte della concorrente censura di “falsa applicazione” dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, che richiede che l’occupazione del suolo pubblico soggetta a canone si estrinsechi “attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture”, nella specie chiaramente mancante, il Tribunale ha ritenuto che il canone sia dovuto da Fastweb a titolo di “occupazione mediata”, in base alla seguente (impugnata) motivazione:

“Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell’erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni di Fastweb spa), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico. L’espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce della volontà del legislatore come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad “una modificazione della realtà esterna”. Invero il canone è imposto a tutti quei soggetti che si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. E poiché è incontestato che Fastweb spa si avvale mediatamente (o virtualmente che dir si voglia) della rete infrastrutturale di Tim/Telecom spa si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma e soggetto tenuto al pagamento”.

II.2 Critica della sentenza.

Anzitutto, il titolare della rete che nel Comune di Berbenno offre il servizio a Fastweb non è Telecom, come frettolosamente affermato dal Tribunale, ma è Open Fiber, operatore che è solo concessionario e non anche Società di vendita.

Ciò detto, l’interpretazione del Giudice, che degrada l’“utilizzo materiale” a mero

“utilizzo di fatto”, anche “virtuale”, **svilisce la precisa scelta terminologica del Legislatore** e crea una imposizione basata su una presunzione di occupazione che non ha riscontro nella realtà “materiale”.

Il requisito di “utilizzo materiale” contenuto nella Legge n. 160/2019 non è suscettibile di interpretazione atta a ricomprendervi anche la fruizione virtuale – peraltro non della rete ma del servizio – che non è materiale, ma è proprio il suo contrario.

Siamo pertanto di fronte ad una **chiara ipotesi di “falsa applicazione” di una norma che non poteva essere applicata e che invece il Tribunale, previa forzatura (rectius: riscrittura della norma), ha erroneamente applicato**, senza nemmeno indicare in motivazione le ragioni che lo hanno indotto a individuare una diversa “volontà del legislatore”, peraltro insuscettibile di superare l’inequivoco tenore testuale della norma.

L’impossibilità di assimilare la “fruizione virtuale” all’ “utilizzo materiale” è stata efficacemente sottolineata – tra le altre – dalla seguente decisione:

“... l’occupazione mediata, per espressa previsione di legge, deve essere costituita dall’utilizzo materiale di infrastrutture già esistenti.

*Al fine di perimetrare detta condotta, **il legislatore ha utilizzato l’aggettivo “materiale” che, nell’accezione propria del linguaggio comune, si riferisce ad un dato sensibile della realtà esistente, al contrario degli aggettivi “astratto”, “ideale” o “virtuale”, i quali evidentemente alludono ad una dimensione immateriale, che attiene ad un livello che non è quello della materia fisica.***

*Non potendosi, quindi, pretermettere l’aggettivo materiale espressamente utilizzato dal legislatore per delineare la portata precettiva della condotta di occupazione mediata, si deve ritenere che, a fini impositivi, **la condotta rilevante sia solo quella che importa un ulteriore carico aggiuntivo materialmente percepibile sulle infrastrutture già realizzate dal concessionario, mediante installazione di apparati e cavi ulteriori che aumentino il carico sul suolo pubblico.***

Per contro, nella diversa ipotesi oggetto di scrutinio, in cui sussista un utilizzo meramente virtuale della rete fissa già esistente da parte di un operatore di telecomunicazioni, diverso dal concessionario, che non installi cavi ed impianti aggiuntivi, ma si limiti a trasmettere il proprio segnale sugli impianti del medesimo concessionario, non sussiste occupazione materiale mediata del suolo pubblico, non essendovi modifica della realtà fisica e, pertanto, la detta condotta non ricade nel

perimetro della norma impositiva.

Nel caso in esame l'ente creditore non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, ai sensi dell'art. 7 co. 10 della L. 150/2011, la ricorrenza di una occupazione materiale mediata da parte della società appellata, effettuata con installazione di apparati di telecomunicazione sull'infrastruttura già esistente ed idonei a realizzare la modifica materiale della realtà fisica richiesta dalla norma.

Di conseguenza, non può ritenersi fondata la pretesa di pagamento del canone".
(Trib. Viterbo, sent. 19 novembre 2025, n. 692; doc. C, pag. 178)

In sostanza:

*“la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non veicola di per sé una occupazione di territorio ulteriore, rispetto a quella già oggettivamente determinata dalla presenza delle infrastrutture. L'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro (mero) utilizzatore comporterebbe dunque la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un **medesimo episodio di occupazione**” (Trib. Vicenza, sent. n. 83/2025, doc. C, pag. 1).*

E ancora:

*“la dizione normativa postula ... un rapporto di utilizzazione materiale delle infrastrutture, da parte di soggetto diverso dal concessionario (nel caso di specie, TIM), il che implica però, **se si vuol dare un senso al nomen iuris adottato dal legislatore**, la fruizione, effettiva, da parte di soggetto altro, rispetto al concessionario, dei manufatti da quest'ultimo collocati e posti in opera” (Trib. Asti, sent. n. 155/2025, doc. C pag. 46); “assume carattere dirimente, ai fini di individuare i soggetti passivi tenuti al pagamento del canone in questione, l'utilizzazione **comunque materiale** e di fatto del suolo pubblico” (Trib. Vicenza, sent. n. 1209/2025, doc. C, pag. 108).*

II.3 Insussistenza del requisito dell'utilizzo materiale (riproposizione del fatto, occorrendo anche ai sensi dell'art. 342, n.2, c.p.c.)

Si è chiarito che la fruizione virtuale del servizio all'ingrosso offerto dal concessionario di rete è fattispecie diversa e, anzi, opposta rispetto a quella dell'“*utilizzo materiale delle infrastrutture*”.

Il Tribunale, del resto, ha riconosciuto che Fastweb, nel territorio di Berbenno, si limita a fruire virtualmente dell'infrastruttura del concessionario, altrimenti non avrebbe avuto necessità di sostenere l'assimilabilità dell'uso virtuale a quello

materiale.

Anche l'avviso di accertamento impugnato esclude espressamente qualsiasi occupazione fisica del territorio (*"utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione ... senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà"*; doc. 1).

La questione di fatto è dunque pacifica e, pertanto, per mero scrupolo, si ribadisce, occorrendo anche a titolo di ricostruzione del fatto, ex art. 342, n. 2, cpc quanto osservato in primo grado a proposito del rapporto tra Fastweb e la rete infrastrutturale.

Fastweb, infatti, non installa propri cavi nei cavidotti e pozzetti di Open Fiber; non installa apparati o quadri o altro nei cabinet-armadietti stradali dei concessionari di suolo pubblico; non compie alcuna attività o intervento tecnico sulle infrastrutture, neanche in caso di guasti; non ha facoltà di accesso alle stesse neanche per controllo o ispezione e non ne conosce l'ubicazione.

I c.d. partner di Open Fiber, tra cui Fastweb e altre trecento Società di vendita, **si occupano esclusivamente di commercializzazione e assistenza agli utenti** ma non hanno alcun contatto con l'infrastruttura, tanto è vero che, in caso di attivazione della fibra, è un addetto Open Fiber a recarsi nell'abitazione dell'utente e a montare un apparecchio che è marchiato Open Fiber.

Da Open Fiber le Società di vendita ricevono un servizio "chiavi in mano", tanto che Fastweb non solo è priva di rapporto con il suolo pubblico, ma nemmeno è a conoscenza del percorso effettuato dalla fibra ottica.

Anche la **Delibera 623/15/CONS** pubblicata da AGCOM ha spiegato che *"il servizio di 'unbundling virtuale' (al quale sono riconducibili le modalità di prestazione del servizio illustrate nell'atto di citazione) **consiste nella gestione commerciale temporanea di un cliente finale che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell'operatore di accesso**; il servizio è offerto nel caso in cui l'operatore alternativo formuli una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa*

per una temporanea mancanza di risorse fisiche”.

È così confermato che il servizio viene materialmente erogato dal titolare dell’infrastruttura (nel nostro caso, Open Fiber) seppure il cliente intrattenga un rapporto commerciale con un diverso operatore (nel nostro caso, Fastweb).

II.4 Infatti, per quanto riguarda la c.d. rete fissa, Fastweb assicura il servizio sia attraverso impianti propri che mediante convenzioni di servizio:

- in taluni casi Fastweb è titolare dell’intero collegamento tra la propria Rete Primaria, le proprie centrali e la “presa” del cliente, e si avvale di una **propria Rete di Accesso**, cioè proprie centraline di diramazione e propri collegamenti in cavi di fibra ottica, entrambi posti lungo le strade del territorio comunale; in questi casi, Fastweb si fa carico del collegamento completo tra la propria centrale (Core Network) e l’abitazione del cliente;
- in molti altri casi, come a Berbenno, il collegamento tra la “Rete Primaria” di Fastweb e la presa del cliente avviene attraverso l’utilizzo, parziale o completo, di **servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline forniti da altri soggetti** che, tramite le proprie infrastrutture, forniscono servizi di collegamento Wholesale (all’ingrosso) in favore di altri operatori (c.d. OLO: Other Licensed Operator). Tra i soggetti titolari delle infrastrutture, oltre all’ex monopolista TIM – Telecom Italia S.p.a. (da luglio 2024 Fibercop), quale titolare della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della c.d. “Rete di Accesso”, cioè dei cavi posti lungo le strade che, diramandosi, entrano materialmente negli immobili degli utenti, vi è anche **Open Fiber S.p.A.**, operatore che si occupa della realizzazione, gestione e manutenzione della rete in fibra ottica. Il fornitore di questi servizi rappresenta - ai sensi del comma 831 dell’art. 1 della L.160/2019 – il **titolare della concessione per l’occupazione del “territorio comunale”**, comprensivo – secondo la definizione del precedente comma 819 – delle *“aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e*

degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”.

Insomma, **i predetti operatori infrastrutturali (TIM, Open Fiber) forniscono** agli altri Operatori (detti OLO, *Other Licensed Operators*), **attraverso le proprie infrastrutture e cavi, il servizio di collegamento all’utente finale**. Questo servizio a sua volta, può essere realizzato mediante tecniche diverse (VULA, NGA, ed altri servizi di accesso analoghi).

Ad esempio, la modalità tecnica di collegamento e il relativo contratto può essere BITSTREAM NGA (*Next Generation Access*), tipologia di accesso che prevede che l’Operatore sia presente (non sul territorio, né nella centrale del concessionario) esclusivamente in un punto di raccolta collocato a monte; oppure può essere VULA (Virtual Unbundled Local Access), tipologia di accesso che prevede che l’Operatore sia presente (non sul territorio ma) esclusivamente nella centrale del concessionario con un apposito kit di consegna; oppure servizi punto-punto, ad esempio, GEA, BEA, dark fiber.

Con tali modalità di accesso, utilizzate anche nel territorio del Comune di Berbenno, Fastweb può offrire servizi di connessione (sia FTTC che FTTH) ai propri clienti senza essere presente con la propria rete né lungo le strade con propri cavi e cabinet e nemmeno nei cavi di diramazione che entrano negli immobili degli utenti (e, nel modello NGA, nemmeno nelle centrali del concessionario).

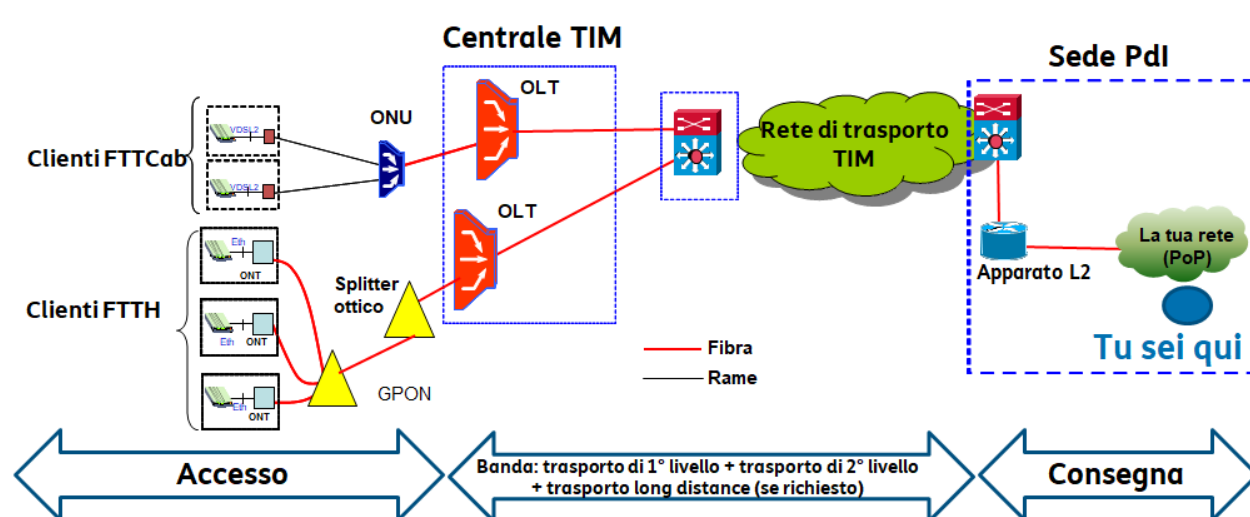
Quindi, in questo caso, la connessione del cliente viene gestita da Open Fiber.

Del servizio fornito da Open Fiber all’ingrosso si fa cenno anche sul sito istituzionale, dove si rappresenta che *“La nostra infrastruttura in fibra ottica è disponibile per tutti gli Operatori di telecomunicazioni a pari condizioni. Pertanto, qualunque soggetto, purché detenga le necessarie autorizzazioni e previa sottoscrizione di un apposito contratto, potrà richiederci un segmento di terminazione. In questa sezione potrai trovare gli Operatori che hanno deciso di utilizzare la nostra rete FTTH”* (**doc. 4**, con elenco dei numerosi Operatori che hanno concluso accordi con Open Fiber, tra i quali, a pag. 6, figura Fastweb).

Si consideri che i contratti di cui sopra realizzano assetti non riconducibili al libero mercato, sia perché l'operatore infrastrutturale è **tenuto a consentire agli Operatori c.d. OLO l'accesso al servizio**, sia perché le relative **condizioni contrattuali**, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di quelli dettati dall'Autorità di Regolazione, sono **uniformi per tutte le Società di vendita**. (si veda, in particolare, la Delibera n. 538/13/CONS dell'Agcom: **doc. 5**)

Le descritte modalità tecnico-contrattuali sono peraltro notevolmente onerose per Fastweb, che è tenuta a compensare il titolare dell'infrastruttura per il servizio di collegamento attraverso la Rete di Accesso oltre che per la manutenzione e gli oneri di occupazione di suolo pubblico. Fastweb, infatti, non ha il controllo della rete di accesso né di parte della rete di trasporto, tanto che la manutenzione e la risoluzione dei guasti è di pertinenza di Open Fiber.

Lo **schema esemplificativo** che segue spiega ad esempio l'architettura di distribuzione BITSTREAM NGA: come si vede l'operatore è presente solo nella fase di consegna (a monte) e si affida completamente a Open Fiber (o a TIM) sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di trasporto che collega la centrale Open Fiber (o TIM) al Punto di Interconnessione.



L'intera tratta che va dal PDI alle abitazioni dei clienti, indipendentemente

dall'architettura posta "a valle" della centrale (FTTC: *Fiber to the Cabinet* / FTTH: *Fiber to the House*), è di pertinenza e gestione del concessionario e trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l'uso delle VLAN (Virtual LAN).

In definitiva nei contratti di specie Fastweb non ha alcun impianto e/o infrastruttura della propria rete nel territorio comunale, come peraltro riconosciuto dall'avviso impugnato e non può definirsi utilizzatore "materiale" della rete di distribuzione, come richiesto dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019: infatti Fastweb si limita a fruire di un servizio di trasporto fornito da Open Fiber e non dispone fisicamente e materialmente dell'infrastruttura, né tantomeno la "utilizza".

II.5 Del resto, col termine "occupazione" si intende la "*sottrazione dell'area all'uso pubblico ed indifferenziato della collettività per destinarla ad un uso singolo e commerciale*" (TAR Lazio – Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2021, n. 6533; analogamente Cass. Civ., V, 9 novembre 2021, n. 32869, secondo cui si ha occupazione, ai fini dell'applicazione delle norme TOSAP, quando si determini "*un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico*").

L'occupazione, pertanto, presuppone una "***relazione materiale instaurata con la cosa***" da parte dell'occupante (cfr. Cass. Civ., sez. V, sent. 8 settembre 2017, n. 21018). Sul punto, **Cass. Civ., ss.uu., 7 maggio 2020, n. 8628**, ha ulteriormente precisato che la "*relazione materiale instaurata con la cosa*" è condizione necessaria e sufficiente perché possa parlarsi di occupazione di suolo pubblico, indipendentemente dall'esistenza e dalle caratteristiche di un titolo giuridico che giustifica l'occupazione stessa.

Anche l'occupazione mediata richiede dunque una "*relazione materiale instaurata con la cosa*" che dovrà essere diversa dalla occupazione diretta, ossia "mediata" dalla infrastruttura del concessionario, ma non potrà essere del tutto assente. Questo requisito è stato individuato, nel testo vigente, appunto con l'indicazione per cui l'occupazione in via mediata avviene "*attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione*".

L'espressione "utilizzo" non può essere letta estensivamente; per un'elementare esigenza di coerenza sistematica, deve essere intesa in conformità con la nozione generale di "occupazione" (specificata al comma 819 ma rinvenibile nella complessiva disciplina di cui ai commi da 816 a 836, oltre che nella giurisprudenza sopra citata) e quindi deve ritenersi che richieda almeno la presenza stabile, sull'infrastruttura del concessionario, di oggetti materiali di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità. Altrimenti, non si ha utilizzo materiale, bensì virtuale.

Per esplicitare un esempio concreto di "*occupazione mediata realizzata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione*", basti pensare all'utilizzo di un cavidotto di protezione (per rete idrica o rete elettrica o rete per telecomunicazioni o altro ancora) realizzato dal titolare della concessione del suolo pubblico (meglio sottosuolo) e che venga utilizzato anche per farvi passare e proteggere altro cavo elettrico o il cavo in fibra ottica di un altro soggetto. In questo caso si avrebbe un titolare della concessione che occupa il suolo pubblico e si avrebbe altresì una "occupazione mediata" dello stesso suolo attraverso l'**utilizzo materiale** del cavidotto.

Questa relazione materiale (mediata) fra gli impianti-cavi di un soggetto ed il territorio comunale si realizza frequentemente, ad esempio quando gli Enti provvedono a far concentrare e utilizzare congiuntamente talune infrastrutture come previsto, fra gli altri, dal D.Lgs. n. 33/2016.

La necessità di una relazione materiale trova conferma nella disciplina sanzionatoria delle occupazioni abusive laddove è prescritto (art. 1, comma 822) che "*gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni ... priv(e) della prescritta concessione o autorizzazione o effettuat(e) in difformità dalle stesse o per (le quali) non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone*", con ciò dando per scontato che alla abusività corrisponde una materialità da rimuovere.

In definitiva, nel caso di specie, Fastweb non ha alcun materiale rapporto con le condutture, perché non ha la materiale disponibilità delle stesse e non cura nemmeno

la relativa manutenzione. È quindi semplice fruitore del servizio di rete fornito dal titolare della concessione sulla base di assetti contrattuali rispettosi dei principi elaborati dall'Autorità di settore e disponibili per tutti gli Operatori licenziatari.

II.6 Ora, il Comune di Berbenno, preso atto che Fastweb non ha la titolarità della rete, pretende il versamento del canone anche da parte di Fastweb “... *per l'utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione*” ma, a ben vedere, confessa di non aver tenuto conto del necessario requisito dell' “*utilizzo materiale dell'infrastruttura*”; tanto è vero che nell'avviso di accertamento, nella “*motivazione dell'atto*” precisa “...*senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà*”.

Risulta con ciò **evidente che il Comune, applicando a sproposito il comma 831 (come ha fatto il Tribunale), pretende il canone in difetto di un presupposto essenziale (utilizzo materiale) e, nel contempo, pretende di duplicare il canone per un'occupazione fisica che è in realtà unica.**

In definitiva, anche a voler prescindere (ma non si vede come) dalla norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-quinquies, D.L. n. 146/2021), non sussistono i presupposti impositivi di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, per difetto, in capo a Fastweb (e alle altre c.d. Società di vendita) del requisito dell'“*utilizzo materiale delle infrastrutture*”, espressamente richiesto dalla norma, né quelli degli artt. 48, comma 8, e 51 del “*Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria*” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Berbenno n. 8 del 6.04.2021 (**doc. 3**), atteso che, per quanto chiarito, Fastweb non realizza un'occupazione permanente di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella del titolare della concessione.

*

Numerosi avvisi di accertamento analoghi sono stati annullati in sede giurisdizionale in accoglimento di opposizioni formulate da Fastweb e da altre

Società di vendita, con motivazioni basate su **duplice fondamento** ossia, da un lato, sulla valorizzazione della norma di interpretazione autentica, dall'altro lato, sulla accertata non ricorrenza del requisito dell'“*utilizzo materiale dell'infrastruttura*”, prescritto dal comma 831.

Per non appesantire il presente atto, si rinvia alla allegata **rassegna giurisprudenziale** con i precedenti specifici più significativi, molti dei quali resi in appello (doc. C).

* * * * *

(TERZO MOTIVO DI APPELLO)

SULLA NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. MOTIVAZIONE ERRONEA E INSUFFICIENTE.

III.1 La domanda di nullità.

Fermi i motivi assorbenti che precedono, si è anche dedotta, nel giudizio di primo grado, la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo che, per la sua idoneità *ex lege* a divenire titolo esecutivo (al pari della c.d. ingiunzione fiscale), deve necessariamente fondarsi su un titolo giustificativo che può essere un atto di concessione di suolo pubblico, oppure un verbale di accertamento di abusività dell'occupazione, ma non può essere un'occupazione mediata presuntivamente e/o incidentalmente dichiarata.

Ci si riferisce alla domanda di nullità dell'avviso di accertamento impugnato, formulata da Fastweb nelle conclusioni di primo grado e affidata alle deduzioni svolte nell'atto di citazione (doc. B1, pagg. 20-22) integrate nella prima memoria (doc. B2, pagg. 2-3) e ribadite nelle note conclusive (doc. B4, pagg. 3-4),

III.2 Il capo di sentenza impugnato

Sul punto, il Tribunale si è limitato a osservare quanto segue:

“Il motivo attinente alla previa e formale contestazione della sanzione è infondato. Infatti, l'articolo 36 del regolamento comunale invocato dalla parte ricorrente non

prevede alcuna sanzione di nullità del successivo accertamento esecutivo in caso di mancata elevazione del verbale al trasgressore. E' doveroso per completezza rilevare, ad ogni modo, come parte convenuta abbia versato in atti sia il regolamento del Comune di Berbenno (BG) sia il regolamento di altro ente territoriale (Comune di Berbenno Valtellina -SO-) (sic!) generando confusione nella istruttoria del Tribunale."

III.3 Critica della sentenza: omessa pronuncia.

Anzitutto, va rilevato che la sentenza non si è espressa sulla questione riguardante l'impossibilità di azionare la pretesa da c.d. occupazione mediata attraverso lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo, incorrendo in omessa pronuncia.

L'avviso impugnato muove dalla ritenuta "occupazione mediata" da parte di Fastweb della rete infrastrutturale fissa, ma in mancanza di alcuna previa contestazione e verifica e facendo leva sulle presumibili utenze di Fastweb, induttivamente desunte dalle quote di mercato, individuate sì dall'AGCOM, ma su base nazionale (!).

Un siffatto accertamento, che dovrebbe basarsi su "*idonea documentazione*" (ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali: "*sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza*") è stato dunque affidato a elementi presuntivi.

Ne deriva l'illegittimo ricorso allo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo che, per la sua idoneità a diventare titolo esecutivo in caso di decorso del termine di impugnazione (v. art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019), **deve necessariamente veicolare una pretesa certa, liquida ed esigibile, ossia basata su "fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati"** (v. Trib. Napoli, sent. 22 luglio 2025, n. 7367 e, in tema di c.d. ingiunzione fiscale, Cass. Civ., I, sent. 15 giugno 2020, n. 8162; *conf.* 20 luglio 2025, n. 20295) e giammai su accertamenti presuntivi, per di più promananti da soggetto diverso dal Comune: il "metodo induttivo" è infatti di per sé inadeguato e non ammesso per le entrate locali perché non soddisfa requisiti di specificità e certezza.

La richiesta del 12.11.2024 inviata a Fastweb dalla Archivio Solution S.p.A. di Napoli (v. all. 2 mem. Comune 18.9.2025) non integra accertamento ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 ma rappresenta un mero invito a rendere una dichiarazione; controparte ha confessato, poi, che tale invito mirava a “*scongiurare il ricorso alla procedura di stima **presuntiva** prevista dalla legge*”, quale legge non è dato sapere, e pertanto non rappresentava idoneo titolo giuridico presupposto quale avrebbe potuto essere, a esempio, un provvedimento di concessione di suolo pubblico intestato a Fastweb.

D'altra parte, l'affidamento diretto del “*servizio di accertamento del canone*” alla Archivio Solution (v. all. 1 mem. Comune 18.9.2025), desta perplessità, anche considerato che, come emerge dalla Determinazione di affidamento del 25.10.2024 prodotta dal Comune, si tratta di un servizio che viene retribuito solo in caso di effettivo incasso (“*l'impegno di spesa verrà assunto esclusivamente in corrispondenza dell'avvenuto incasso*”), il che mette in luce la sussistenza di un conflitto di interessi che mina l'attendibilità delle conseguenti richieste di pagamento. Pertanto, la pretesa in questione non poteva essere azionata tramite avviso di accertamento esecutivo e il Tribunale non ha colto l'essenza della contestazione.

III.4 Critica della sentenza (segue)

Il Tribunale, del resto, non ha potuto negare che la pretesa del Comune sia stata azionata senza un titolo. Fastweb, infatti, non è titolare di alcuna concessione di occupazione di suolo pubblico e, inoltre, non è occupante abusiva.

La motivazione di rigetto del Tribunale sembra travisare la natura della contestazione e sembra dare per scontato che si versi in ipotesi di occupazione abusiva.

Infatti, il tema sollevato non è la “*previa e formale contestazione della sanzione*” ma è la **necessità che sia rinvenuto un titolo fondante la pretesa**, titolo che, come detto, non può essere l'atto di concessione di suolo pubblico (perché Fastweb non è concessionario) e non è nemmeno il verbale di accertamento di occupazione abusiva (che, come confermato dal Tribunale, non esiste).

Se il Comune avesse voluto (erroneamente) individuare in Fastweb un'occupante abusivo sarebbe stato necessario il relativo accertamento (ai sensi dell'art. 36 del regolamento Comunale) e non rileva che l'art. 36 del Regolamento non sanzioni espressamente con la nullità l'avviso di accertamento esecutivo adottato senza previa contestazione di abusività e, più in generale, senza un titolo giustificativo.

La sentenza, in buona sostanza, non nega l'errore procedurale ma pretende di rinvenire nel Regolamento Comunale una espressa sanzione di nullità dell'avviso di accertamento, quando invece sarebbe stato sufficiente rilevare che, peraltro in contraddizione con la tesi dell'occupazione mediata, Fastweb viene (incidentalmente) ritenuta occupante abusiva, prescindendo dall' "*apposito processo verbale di constatazione*" che è necessario "*in tutti i casi di occupazione abusiva*" (art. 36 del Regolamento Comunale, **doc. 3**) e che inoltre presuppone inevitabilmente la materialità dell'occupazione.

In realtà, come più volte detto, e come dedotto anche a proposito della erronea quantificazione della sanzione, **Fastweb non è affatto occupante abusivo ma, se lo fosse stato (come sembra ritenere il Comune), sarebbe stato comunque imprescindibile un previo verbale di accertamento, che non è un mero adempimento formale, ma un atto presupposto necessario che garantisce il diritto di difesa e la corretta formazione della pretesa dell'ente.**

La sua omissione, specialmente in un contesto in cui l'abusività è tutt'altro che palese, vizia l'intero procedimento impositivo, rendendo illegittimo l'avviso di accertamento che ne consegue.

* * *

(QUARTO MOTIVO DI APPELLO)

SULLA ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE: VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL REGOLMANENTO COMUNALE. ERROR IN IUDICANDO.

IV.1 Il capo di sentenza impugnato

Il Tribunale ha anche respinto il motivo di opposizione proposto in via subordinata (cfr. atto di citazione, doc. B1, pag. 22) e riguardante la **erronea quantificazione della sanzione**, nella misura del 100% del canone non versato, osservando:

“Infondato, infine, anche l’ultimo motivo di opposizione riguardante l’asserito erroneo calcolo della sanzione dell’avviso di accertamento poiché l’importo richiesto dall’ente territoriale è rispettoso della modalità di calcolo indicata nel comma terzo dell’articolo 58 del Regolamento Comunale ossia che “per le occupazioni abusive...si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ...del canone dovuto...”. Ora, poiché il canone richiesto ammontava ad euro 3.484,43 il Comune era legittimato a richiedere il medesimo importo a titolo di sanzione.

IV.2 Critica della sentenza.

Tale motivazione è viziata da un errore di sussunzione. La fattispecie dell’“occupazione abusiva” presuppone una modificazione materiale della realtà in assenza di titolo concessorio.

Come ampiamente dimostrato, Fastweb non ha realizzato alcuna occupazione materiale, né diretta né mediata, del suolo pubblico. La sua posizione non può quindi essere assimilata a quella di un occupante abusivo.

La pretesa del Comune, per come formulata, attiene a un presunto omesso versamento di un canone che si riterrebbe dovuto in base a una specifica interpretazione di legge. Pertanto, la norma sanzionatoria applicabile, se mai ve ne fosse una, sarebbe quella prevista per l'omesso o tardivo versamento.

E l’art. 58 del Regolamento Comunale di Berbenno, come dedotto in primo grado, stabilisce per tale ipotesi una sanzione del 30%: *“sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato”*

Il Tribunale ha dunque erroneamente qualificato la condotta di Fastweb come "occupazione abusiva", dimenticando che l’abusiva occupazione richiede sempre una materialità, ossia una modificazione della realtà (cfr. artt. 51 e 36, comma 1 del Regolamento).

Di conseguenza, il Tribunale ha **erroneamente applicato il comma 3, anziché il comma 1, dell'art. 58 del Regolamento Comunale** e dunque una norma sanzionatoria sproporzionata e non pertinente al caso di specie, in violazione del principio di legalità e di tipicità della sanzione.

Ne deriva che la sanzione è stata erroneamente quantificata in misura pari al canone asseritamente omesso (€ 3.484,43) anziché nella misura del 30% del canone asseritamente omesso, ossia € 1.045,32.

Pertanto, il Comune, pur avendo espressamente disciplinato la misura della sanzione, in virtù del proprio potere regolamentare conferito dalla Legge e che può spingersi fino alla istituzione di esenzioni e riduzioni, ha apertamente violato l'art. 58 del proprio Regolamento, senza giustificazione alcuna.

* * * * *

(QUINTO MOTIVO DI APPELLO)

SULLA RIFORMA DELLA STATUZIONE SULLE SPESE DI LITE.

La sentenza impugnata ha infine compensato le spese di lite *“alla luce del contrasto giurisprudenziale di merito rilevato sul punto nonché per l'improvvido deposito da parte del Comune di Berbenno di regolamento di altro ente”*.

Tale statuizione dovrà essere riformata. L'esito del presente appello, che si confida sarà di totale accoglimento, comporterà la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente applicazione del principio della soccombenza.

Il Comune di Berbenno dovrà pertanto essere condannato alla refusione integrale delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

* * * * *

Per le ragioni esposte, e, comunque per quelle di giustizia, con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, Fastweb S.p.A., come rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

il **COMUNE DI BERBENNO** (C.F. 00313890162), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Europa n. 7 – 016023 Berbenno (BG), PEC comuneberbenno@legalmail.it (estratta da Registro IPA), elettivamente domiciliato presso il difensore di primo grado, Avv. Maria Voccia De Felice, PEC mvocciaordsa@pec.giuffre.it (estratta da INI-PEC), a comparire avanti la Corte di Appello di Brescia, Sezione e Giudice designandi, all'udienza che sarà tenuta il **14 aprile 2026**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-*bis* c.p.c., con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c., compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c. Con avvertenza che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) annullare e/o riformare la sentenza n. 1523 del 25.11.2025 del Tribunale di Bergamo, Sezione Seconda Civile, dott. Paolo Rossi;
- 2) per l'effetto, accogliere le seguenti domande, proposte da Fastweb S.p.A. nel giudizio di primo grado: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, accertato che Fastweb S.p.A. non è concessionaria dell'infrastruttura di rete sita su territorio comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, in tutto in parte, l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 6.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno, e ogni altro atto o avviso ad esso connesso o consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto da Fastweb S.p.A. al Comune di Berbenno per le annualità 2021,

2022, 2023 e 2024 a titolo di canone unico patrimoniale, indennità, interessi e, comunque, a titolo di sanzioni”.

3) condannare il Comune di Berbenno in persona del legale rappresentante p.t., a restituire le somme eventualmente versate da Fastweb S.p.A. in esecuzione dell’avviso di accertamento illegittimo;

4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori.

*

Si producono, oltre all’originale notificato del presente atto di citazione in appello, i seguenti atti e documenti:

A) Sentenza Trib. Bergamo n. 1523 del 25.11.2025 in originale informatico

A-bis) Notifica sentenza in data 28.11.2025;

B) Fascicolo Fastweb S.p.A. di primo grado con i seguenti atti e documenti, tutti conformi ai corrispondenti atti e documenti del fascicolo telematico R.G. n. 2320/2025 dal quale sono stati estratti: **B1)** Atto di citazione 16.4.2025; **1)** Avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 6.02.2025; **2)** Notifica pec avviso di accertamento in data 15.02.2025; **3)** Regolamento Comunale CUP Berbenno; **4)** Elenco Operatori estratto da sito Open Fiber; **5)** Delibera 538/13/CONS di Agcom; **6)** Dossier Senato conversione DL 146/2021; **7)** Emendamenti al D.L. 228/2021 non approvati; **8)** Trib. Vicenza, sent. 21.1.2025; **9)** Trib. Padova sent. 20.9.2023; **10)** Trib. Padova sent. 2.1.2024; **11)** Trib. Perugia, sent. 5.7.2024; **12)** Trib. La Spezia, sent. 21.3.2025; **13)** Trib. Perugia, sent. 18.3.2025; **14)** Trib. Asti, sent. 12.3.2025; **15)** Trib. Rovigo, sent. 10.3.2025; **B2)** Prima memoria integrativa 8.9.2025; **B3)** Terza memoria integrativa 19.9.2025; **B4)** Note conclusive autorizzate del 18.11.2025; **B5)** Attestazione di conformità fascicolo I grado.

C) **Rassegna giurisprudenziale aggiornata (24 sentenze).**

*

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa di appello ammonta ad € 7.173,00 e che pertanto il contributo unificato è dovuto e sarà anticipato nella misura di € 355,50, oltre diritti di cancelleria.

Roma, 18 dicembre 2025

Avv. Paolo Caruso